

1501347-73.2022.8.26.0470

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO FERNANDES LIMA

Comarca: Porangaba

Foro: Foro de Porangaba

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 01/11/2022

... se dedica a atividade criminosa de tráfico, seja beneficiado com a substituição. No presente caso, o réu foi preso em atividade de tráfico de entorpecentes que envolvia um adolescente. Assim, comprovado o tráfico danoso à sociedade, tal conduta que não pode ser equiparado a crime de menor potencial ofensivo, passível de ser beneficiado com a substituição da pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porangaba

Foro de Porangaba

Vara Única

RUA VEREADOR BRAZ GICA DA PAZ 193, Porangaba-SP - cep 18260-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1501347-73.2022.8.26.0470 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501347-73.2022.8.26.0470

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 26075324 -

DEL.POL.PORANGABA, 2187762 - DEL.POL.PORANGABA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDRÉ LUÍS MOREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO FERNANDES LIMA

Vistos.

ANDRÉ LUIS MOREIRA DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado por infração ao artigo 33, caput, combinado com o artigo 40 inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 12 de julho de 2022, por volta das 10h00min; na rodovia Presidente Castelo Branco - SP 280, Km 158, na praça do pedágio, nesta cidade e comarca de Porangaba, guardou e transportava entre estados da federação, para fins de entrega a consumo de terceiros, 03 tijolos plásticos, com peso líquido de 3.198,67g e 10

tijolos de "Skunk", com peso líquido de 4.862,74g, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que o réu recebeu as drogas na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul, de pessoa desconhecida, acondicionou-as em uma bolsa e uma mochila, embarcou em um ônibus da viação Motta, sentou na poltrona 43 e seguiu viagem com destino a São Paulo.

Consta que, na praça do pedágio, nesta comarca, policiais rodoviários efetuaram uma revista de rotina no interior do ônibus e atentaram que o réu, que estava na poltrona 43, ao visualizá-los, apresentou nervosismo incomum.

Os policiais, desconfiados, realizaram inspeção, localizando atrás do banco do réu as drogas mencionadas envoltas em pó de café, acondicionados três tijolos em uma mochila e dez tijolos em uma bolsa.

O réu teria confirmado que aceitou uma proposta de recompensa de R\$ 5000,00 para transportar a droga para São Paulo.

Notificado, o réu apresentou resposta à acusação, na forma do artigo 55 da Lei n.º 11.343/06 (folha 95).

Denúncia recebida em 10 de agosto de 2022 (folha 100 a 101).

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas comuns arroladas pelas partes e interrogado o réu (folhas 124 a 126).

O Ministério Público, em debates, requereu a procedência da pretensão punitiva, por entender provada a acusação relativa ao tráfico de entorpecentes com causa de aumento de pena (folhas 124 a 126).

A Defesa, em debates, argumenta, em síntese, não há provas suficientes para a condenação. Pretende a absolvição, ou subsidiariamente, em caso de condenação, em caso de condenação, o réu confessou a infração e faz jus à causa de diminuição de pena (folhas 124 a 125).

Este é, em síntese, o relato do essencial.

Fundamento e DECIDO.

A pretensão punitiva é procedente.

Assinalo inicialmente que nada impede que o viciado com higidez mental, responda como traficante, aplicando-se a norma do artigo 33, absorvido o delito do artigo 28. Nesse sentido, com as modificações necessárias, é a nossa jurisprudência. Acerca dos benefícios do artigo 19 da Lei Federal nº 6.368/76, assevera-se que a mera condição de dependência, se não diagnosticada como enfermidade da mente, não consubstancia a base biológica da inimputabilidade ou semi-responsabilidade, como preleciona Vicente Greco Filho.

Quanto aos demais pontos, a materialidade do crime está em evidência no boletim de ocorrência (folhas 13 a 15); no auto de exibição e apreensão (folhas 18 a 19) e pelo exame químico toxicológico (folhas 38 a 43).

Quanto à autoria, ao ser interrogado em audiência judicial, o réu Guilherme admitiu que foi ao local para comprar maconha; resolveu trocar seu celular por crack, mostrou o celular para um menino que estava vendendo droga, no momento em que chegaram os policiais dispensou a maconha; não soube dizer quem era a pessoa que

pegou o celular para olhar (folha 260).

Quando interrogado em audiência, o réu confessou que transportava os entorpecentes de Dourados para São Paulo, admitiu que receberia cinco mil reais pelo transporte. Alegou que tinha dívida de drogas e aceitou fazer o transporte para quitar a dívida com traficantes. Nunca teve passagens policiais e é usuário de crack. Alegou que seria morto se não pagasse a dívida com traficantes.

Durante o contraditório constitucional o policial militar disse que foram apreendidos cinco quilos de maconha e Skunk, em uma fiscalização de rotina em um ônibus da viação Motta. O réu teria admitido que receberia cinco mil reais para transportar o entorpecente de Dourados para São Paulo. O réu não era conhecido dos meios policiais e declarou que foi a primeira vez que ele atuou no transporte de drogas.

O outro policial militar corroborou a versão apresentada por seu colega de farda, disse que foram encontradas duas bagagens, uma bolsa e uma mochila com o passageiro que ocupava a poltrona numero 43 do ônibus, nas bagagens havia pó de café, maconha e Skunk. O réu se identificou como possuidor das bagagens. O réu admitiu que pegou os entorpecentes em Dourados e o levaria para São Paulo. O réu não era conhecido dos meios policiais.

Dispõe o artigo 28, § 2º da Lei Federal nº 11.343/06: “Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. E, no caso destes autos, há indícios suficientes para a classificação do delito como tráfico ilícito de entorpecentes.

Como já afirmado, o crime atribuído ao réu é de natureza permanente (“guardar”, “transportar” com fim de entrega a terceiro – todos os verbos têm o mesmo conteúdo físico que é o reter, a detenção). E, o crime já estava consumado antes da chegada dos Policiais Militares Rodoviários ao local da apreensão. Para a caracterização do delito do artigo 33 da Lei Federal n.º 11.343/06, na modalidade de traficância, não se exige a prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que os elementos indiciários, tais como a quantidade do material apreendido, a conduta e os antecedentes do agente, bem como as circunstâncias da ação policial e da prisão evidenciem a atividade delituosa.

Neste caso, foi demonstrado por prova testemunhal que o réu efetivamente transportava entorpecentes em variedade e quantidade, tudo devidamente acondicionado em pronto para entrega a terceiros, tudo pronto para venda.

A quantidade de substâncias apreendidas (três tijolos de maconha e 10 tijolos de Skunk, entorpecente derivado da maconha) apreendidas com o réu, na bagagem que ele levava no ônibus da Viação Motta; a forma de embalagem dos entorpecentes apreendidos, conjugados às informações prestadas pelo próprio réu, são mais do que indícios de que ele se dedicava à distribuição de substâncias entorpecentes.

A confissão e a prova testemunhal são harmônicas no sentido de que o réu transportava entorpecentes entre os Estados de Mato Grosso do Sul e São Paulo, evidenciado, portanto, que a conduta noticiada nestes autos caracteriza tráfico entre Estados da Federação, o que importa no reconhecimento da causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso V da Lei n.º 11.343/06.

Dessa forma, as circunstâncias em que a prisão dos réus foi realizada podem ser consideradas para caracterizar a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI da Lei n.º 11.343/06.

Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria, Atendendo ao método trifásico de individualização da sanção criminal prevista nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, com vistas à aplicação da pena justa e necessária à reprovação e prevenção do crime, Passo à dosimetria da pena:

Com relação aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, atendendo ao disposto no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, não havendo provas que revelam a personalidade deturpada do réu e atendendo à culpabilidade e à inexistência de antecedentes do réu (folhas 47 e 113), observada primariedade; fixo a pena privativa de liberdade no mínimo legal, perfazendo um total de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não se verificam circunstâncias agravantes passíveis de serem consideradas.

Reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, mas observo que a pena foi aplicada no mínimo legal cominado em abstrato no tipo penal; de modo que deixo de reconhecer a circunstância atenuante, por ser inadmissível redução, na segunda fase de aplicação da pena, aquém do mínimo legal, conforme orientação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Reconhecida causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V da Lei n.º 11.343/06, A pena deverá ser aumentada em um sexto, elevando-se a pena aplicada para de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/2006, porque o réu é primário, ostenta bons antecedentes, não há elementos seguros (desconhecido dos meios policiais, a despeito de não residir na comarca em que fora preso em flagrante) de que se dedica à atividades criminosas e inexistem indicativos de que integra organização criminosa, para diminuir a pena em 2/3 (dois terços), o que totaliza 01 (um) ano, 11 (onze) meses de e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

Observo, no tocante ao regime prisional, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu, incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, afastando a obrigatória imposição de regime de pena inicial fechado a crimes hediondos e assemelhados, tal como na hipótese destes autos, que versam sobre tráfico ilícito de entorpecentes.

Na fixação do regime prisional ao condenado pela prática do crime de tráfico de drogas deverão ser observados os requisitos dos artigos 33 e 59 do Código Penal, conjugados ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Desta forma, atento às circunstâncias da infração penal, aferidas durante a instrução processual, que indicam que, o réu fora surpreendido em momento em que transportava drogas variadas, em grande quantidade, acondicionadas em tijolos, drogas com alto poder de destruição do consumidor. Considerando ainda a circunstância que permite aferir ter o réu colaborado dolosamente para a difusão da substâncias entorpecentes, Além das consequências reais da infração, já que o tráfico ilícito de entorpecentes invariavelmente causa intranquilidade no meio social, por destruir o núcleo familiar dos viciados, além de aumentar os índices de criminalidade, porquanto os usuários, não raras vezes, cometem crimes contra o patrimônio, com ou sem violência contra a pessoa, para obter recursos e assim manter o vício, bem como as despesas do poder público com segurança pública e saúde pública, advindas das internações, cada vez mais frequentes, de novos narcod dependentes, levados a esse estado de dependência por pessoas sem escrúpulos como o réu. A prova produzida deixou bem nítido que o réu concorreu ativamente para suprir o comercio de drogas, esse condenável procedimento evidencia intensa

culpabilidade, evidenciada pelo desprezo pela vida do próximo, indiferença pela destruição da família do viciado, uma conduta social devastadora, Assim, avaliado o caso concreto, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o regime será inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, mesmo que aplicado o disposto no artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal.

Em que pese o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, deixo de aplicar a detração ao réu preso provisoriamente porque no presente caso porque não há nada nos autos comprovando o bom comportamento carcerário do réu, requisito imprescindível para análise da progressão de regime. A detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena, de modo que se este não for alterado, sobretudo neste caso em que a pena inicial deve ser descontada em regime fechado por expressa previsão legal, não pode haver cálculos para diminuir a reprimenda, sob pena de se interferir na competência do Juízo da Execução Penal. Assim, no presente caso, o regime de cumprimento de pena não será alterado, não obstante o período de prisão provisória do réu.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, avaliado o caso concreto deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por entender que a concessão desse benefício é incompatível para o agente que está sendo condenado pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas, crime equiparado a crime hediondo.

Mesmo porque o artigo 44, inciso III do Código Penal obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito àqueles que por sua personalidade, como o réu, que se dedica a atividade criminosa de tráfico, seja beneficiado com a substituição. No presente caso, o réu foi preso em atividade de tráfico de entorpecentes que envolvia um adolescente. Assim, comprovado o tráfico danoso à sociedade, tal conduta que não pode ser equiparado a crime de menor potencial ofensivo, passível de ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos porque o regime prisional para os crimes de tráfico de entorpecente vem estabelecido em lei especial, que derroga a geral nas matérias em que prevê de forma específica, no caso a Lei n.º 8.072/90; Ademais, a substituição é vedada pelo artigo 33 § 4º da Lei n.º 11.343/06.

A substituição da pena privativa e liberdade por restritivas de direitos não é cabível na espécie, porque se mostra insuficiente à prevenção e repressão do ilícito penal (art. 44, III do Código Penal).

Os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal são cumulativos, devendo estar integralmente presentes para que seja concedida a substituição.

Dessa forma, ante a não observância dos requisitos cumulativos dispostos no artigo 44 do Código Penal, a substituição da pena é inadmissível.

Acrescento que a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos também é vedada pelo artigo 44 da Lei n.º 11.343/2006.

Cumpridos mais de dois terços da pena privativa de liberdade, atendidos os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, e artigos 131 e seguintes da Lei de Execuções Penais, o réu poderá ser beneficiado com o livramento condicional; conforme artigo 44, parágrafo único da Lei n.º 11.343/06.

Quanto ao valor unitário da pena pecuniária, considerando-se a situação financeira

dos réus, é fixado no mínimo legal (artigo 43 da Lei Federal n.º 11.343/06).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar ANDRÉ LUIS MOREIRA DA SILVA, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 11 (onze) meses de e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado nos termos do artigo 2º, § 1.º da Lei n.º 8.072/90 com redação dada pela Lei n.º 11.464, de 28.03.2007 - DOU 29.03.2007 e ao pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", com a causa de aumento do artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06.

Durante o processamento de eventuais recursos interpostos contra a presente sentença condenatória, o réu que se encontra custodiado deverá permanecer preso. Este Juízo vem adotando o entendimento de que nos delitos de tráfico de entorpecente, o regime prisional deve estar em consonância com o que determina o artigo 2º, § 3º, da Lei Federal n.º 8.072/90, principalmente, como no caso dos autos, onde o a atividade ilícita dos réus, dissemina substâncias nocivas e fomenta a prática de outros crimes, em especial aqueles contra o patrimônio. Aliás esse entendimento já foi prestigiado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no venerando acórdão proferido nos autos do HABEAS CORPUS n.º 205.806-3/4, da Comarca de São José do Rio Preto, da Colenda Primeira Câmara Criminal, relator eminente Desembargador ANDRADE CAVALCANTI, j. 15/4/96, votação unânime. A jurisprudência prevalecente é nesse sentido (RHC 1.141 da 5ª Turma do STJ, DJU, 10 jun. 1.991, pág. 7857; TJSP, HC 160.747, JTJ 155/328; TJSP, HC 78.729, 6ª Câmara; TJSP, HC 77.699, 4ª Câmara; RJTJSP 118/551, 120/586, 122/546, 126/438; RT 643/298; RTJ 146/619 (STF); e RHC 545, 5ª Turma (STJ), e está cristalizada na Súmula nº 9 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, reforçada por decisão do Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, em venerando acórdão relatado pelo eminente Ministro NERI DA SILVEIRA, que deixou expresso não assegurar a "Convenção Americana sobre Direitos Humanos" (Pacto de São José da Costa Rica) qualquer imunidade à prisão processual: "Ora, cuida-se, aí, de princípio de nosso vigente sistema constitucional, sendo inclusive, não menos importante, a regra de presunção de inocência até o trânsito em julgado da decisão. Não vejo, pois, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, invocada da tribuna, qualquer acréscimo nas garantias individuais e na proteção ao réu. A prisão do art. 594 do Código de Processo Penal não é inconciliável com a regra do art. 5º, LVII, da Constituição, conforme tem esta Corte proclamado. Não há ver, na Convenção em referência, regra de maior eficácia do que o sistema da Constituição, nem se pode entender que norma internacional faça inserir, em nosso ordenamento, preceito em conflito com a Constituição. Esta, como se acentuou, consagra, também, o duplo grau de jurisdição, tal como na Convenção. Não vejo, a partir daí, por igual, haja a Convenção revogado a norma do artigo 594 do Código de Processo Penal" (Habeas Corpus nº 72366-SP, julgado em 13 de setembro de 1.995).

Em tema de proteção ao status libertatis, referido pacto proclama que "ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente fixadas pelas Constituições dos Estados-Partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas" (artigo 7º, n.º 2). E, como muito bem observou o eminente Ministro CELSO DE MELLO: "na realidade, essa cláusula da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ao remeter ao plano do direito positivo interno a definição normativa das hipóteses de supressão da liberdade pessoal, admite que o sistema jurídico nacional ou doméstico de cada Estado institua – como o faz o ordenamento estatal brasileiro – os casos em que se legitimará a privação antecipada do status libertatis do réu ou condenado" (Habeas Corpus n.º 72.610-MG, julgado em 05.12.95, cujo despacho foi publicado no DJU de 1º.02.96, pág. 279).

Vedado, portanto, ao réu o direito de recorrer em liberdade, por vedação expressa do artigo 2º, § 3.º da Lei n.º 8.072/90; Mesmo porque, o réu foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado e a segregação impedirá a continuidade do tráfico por ele desenvolvido.

Recomende-se o réu na prisão em que ele se encontra, uma vez que não poderá recorrer em liberdade pelas razões retro expostas.

Decreto a perda em favor da União de bens ou valores apreendidos, na forma do artigo 91, inciso II, "b" do Código Penal, observado o disposto no artigo 60 da Lei nº 11.343/06.

Transitado em julgado, o réu terá o seu nome lançados no livro "Rol dos Culpados".

Custas processuais na forma da lei n.º 11.608/03 (100 UFESP's).

Publique-se; Intimem-se, Comunique-se.

Porangaba, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA